

一、宪法的制定

(一) 制宪权:

1. 决定国家的政治存在样式的权力

创制法秩序的权力

与立法权的区别?

主权——制宪权——宪法——立法权——法律

宪法制定完成后制宪权即消失

2. 处于政治和法的交汇之处 **制宪权之后才有法秩序**

规范宪法学(中国)认为,制宪权不属于宪法学的研究范围

施密特:不受一切规范约束,可自由决断的绝对性的实力

错误,立宪主义宪法不承认,人权是存在的与生俱来的,制宪不能侵犯人权

3. 现代制宪权的理论基础

(1) 根本法 宪法是自由的国民签订的社会契约,高于普通法律

制宪权高于立法权

(2) 人民主权与权力分立

制宪权的主体:人民 人民主权的双重含义

西耶斯融合了卢梭的社会契约论和孟德斯鸠的权力分立观念:主权属于国民,但制宪权和立法权需委托不同的国民代表行使。

制宪权代表:新利益集团的代表

(3) 立宪主义:有限政府 人权保障 (受人权约束)

制宪权受制于现代宪法基本价值的根本规范:先于国家的人权保障原则

制宪权是主权的体现

(二) 制宪权与主权、修宪权

1. 国民主权存在与国民的制宪权中,制宪权和国民主权是一体两面的关系。(西耶斯)

2. 在法的自然状态中,制宪权以原始姿态发动。制定宪法后,其任务实现,即转化为主权,不再发动。**处于休眠状态**

如果发生革命,制宪权再次从主权中“破茧而出”,形成新的宪法/为了“旧宪法”因应社会的变动,另外形成一种组织化的权力,即修宪权。(小林直树)

3. 制宪权:主权

修宪权(制度化的制宪权)

新中国只有一次制宪,其余都是宪法修改。(3)

二、宪法修改

1. 宪法修改的理论

可变性:要求宪法与普通法律一样修改

安定性:宪法的社会契约性质,否认宪法修改(将人民主权理解为实体意义的人民)

折衷:刚性宪法修改程序的特殊性-**提高修宪难度**

成文宪法是刚性宪法

2. 宪法修改的程序

(1) 修宪机关与立法机关完全分离

美国各州的修宪程序 由制宪会议修改

不是议会

(2) 修宪动议为立法机关,但决定机关为特殊机关

美国联邦宪法、日本宪法

(3) 修宪机关与立法机关重合,但程序特殊

中国:第64条 宪法的修改,由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议,并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。

(4) 三个程序环节

修宪动议的提出(由宪法规定的机关行使)

草案的制定 → 表决

联邦政府请各州同意

表决

三、宪法解释

(一) 宪法解释的法适用性质

法律方法层面的法律解释：个案解释 将抽象的、一般性的宪法条文运用于具体案件之中所发生的“理解”活动

(即法适用) (针对案件如何理解法条)

中国式法律解释(抽象解释)：实质意义上的立法

根本原因：立法机关法律供给能力弱，全国人大年开一次会，常委人少力量弱，国家在立法层面投入少

(二) 宪法解释机关

宪法明文规定的宪法解释机关——宪法审查机关，有权作出宪法判断

但实质意义上有权解释宪法的并不限于此

中国 全国人大常委会(最终解释，作出合宪性判断)

类型：司法机关——普通法院 宪法法院

政治机关——宪法委员会，议会

(三) 宪法解释方法

(根据法条间/前后文的关系)

解释方法的位序：文义解释——逻辑、体系解释——目的论解释——漏洞填补

一般意义上的法律方法：

(主观/客观目的)

1. 文义解释：法律解释的起点——找法条

大多数人认同的通常含义

根据宪法条文的字义所进行的解释

不能局限于字面含义，还需照顾到某些用语在法律语言中的特殊用法，以及规范语言的意义脉络

ex: 德国宪法对“科学”一词的解释 / 硫酸氢可区算作武器

2. 逻辑——体系解释

根据法律的体系思维，即法律条文在体系中的地位 and 相互关系，来确定被解释规范的内容以及冲突规范的优先性。

西谚：“只有理解了整体，才能理解部分”

例：美国宪法上的选举权

3. 目的论解释

根据宪法条文的目的所作的解释，

当纯粹的文义解释、逻辑体系解释无法完成解释任务时

客观目的：规范目的，宪法条文当下的意义

主观目的：立法原意，制宪者的原初意图

年代过于久远而难以考证且无法适用于现代社会

“结社隐私权”：从结社自由的目的推导出的权利

全国有色人种协会诉阿拉巴马州 (N.A.A.C.P. v. Alabama)

4. 漏洞填补

不保护隐私则安全受威胁

解释方案超出法条文义范围，法律续造

可以分为：开放的漏洞——应该规定但没有规定(根据立法目的判断) ex: 强奸罪——男生被强奸只能算强制猥亵

隐藏的漏洞——有相关法律规定，但过于粗糙和笼统，且直接适用会导致结果不公(也可以根据立法目的判断)

超越法律的漏洞——法律和法律不明确，立法目的(包括对意义)也不明确 ex: 美国堕胎案——三又四分的标准近期推翻(考虑对女性健康影响，胎儿发育程度)

宪法特有的解释方法

以司法违宪审查制度为前提

(1) 法律的合宪性推定

实施司法审查权时，原则上应当推定该法律为合宪，除非判断出现了“合理怀疑”的情形。

原理：尊重代表多数意见的立法机关的意思；立法、行政、司法三权平等，相互间不随意

否定其他权力，相互礼让的三权分立原则

(明显违宪，违宪行为在人合理判断之内)

ex: 马伯里诉麦迪逊案

(2) 法律的合宪性解释原则

A.法院在司法审查过程中，有关法律存在两种以上解释可能，其中一种为合宪有效，其他解释为违宪无效，则应当采用使法律成合宪有效的解释。

B.在合理的可能情形下，不将法律解释成违宪无效

“解释法律的基本原则，在于救济其穷，不在于存心破坏；就同一法律有两种可能之解释，如其中一种是合宪解释，法院显然有义务，选择救济法律之穷的解释”——法教义学的精髓

在违宪审查中，应该在合理可能的范围内，推定立法机关的立法意旨，是在宪法体制下，依据宪法所赋予的原则行使；不得轻易推测立法机关的立法意旨，存心逾越宪法规定的权能。——不得审查立法机关的立法动机

两者的共同点：除非宪法条文上已经表现出明白而毫无疑义的违宪，否则法院应认定议会并不具有侵犯宪法限制的意图。(要积极推定法律合宪性，消极避免解释为违宪)

区别：合宪性推定——有必要对合宪性做一判断时，积极推定法律的合宪性

法律的合宪性解释——法律发生合宪性疑义时，消极地避免将法律解释成违宪，或者尽可能地消极避免解释合宪性问题。这一原则是否采用，法院存在很大的斟酌、裁量空间。如利益衡量可对这一原则产生冲击。